

1501203-17.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501203-17.2021.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501203-17.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2273820/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 15026359 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL,
2303/21/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2273820 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso III (perigo comum), do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 165/169), a partir de data desconhecida, até o dia 04 de outubro 2021, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, vulgo "Carneiro", portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 04 de outubro de 2021, por volta de 13h40min, na Avenida Rio Paraná, nº 421, COHAB Beira Rio, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, vulgo "Carneiro", por meio que resultou perigo comum, matou a vítima Nivaldo Dionísio Dias Júnior.

A denúncia foi recebida na data de 12/11/2021, concomitantemente, fora decretada a

prisão preventiva do acusado (fls. 171/173).

O réu foi citado na data 29/11/2021 (fls. 184) e apresentou resposta à acusação as fls. 188/208.

Pedido de revogação da prisão preventiva indeferido a fls. 263/265 e fls. 338/339. Realizada audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e feito o interrogatório do réu.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais (fls. 387/402 e fls. 405/426). O MP pugnou pela impronúncia do acusado em relação ao crime de homicídio e condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteou a impronúncia total.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11, 19 e 26); pelos rebatimentos fotográficos (fls. 13/14); pelos laudos dos objetos relacionados ao homicídio (fls. 33/40, 50/55, 77/84, 213/215 e 216/222); pelo laudo necroscópico da vítima (fls. 46/49); pelas imagens e vídeos das câmeras de monitoramento (fls. 65/76 e mídia acondicionada em cartório); pelo laudo pericial do local do crime (fls. 85/131); pelo exame de confronto balístico (fls. 374/382); pelos depoimentos em solo policial de Gabriela Cheron Vieira Dias (fls. 20), Jonas Roberto da Silva (fls. 21), Rodrigo Teixeira da Silva (fls. 22), Alessandro Rogério Yoshida (fls. 23), Paulo Henrique Rodrigues de Melo dos Santos (fls. 62); e EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL (fls. 41/42), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Em solo policial, a testemunha Gabriela Cheron Vieira Dias declarou que: “(...) Sou esposa de Nivaldo, sendo que nesta data por volta das 13h30min horas estávamos em nossa casa, sendo que Nivaldo que estava sentado na área frontal adentrou correndo para dentro da casa e saiu do mesmo jeito, mas não vi se carregava alguma coisa. Corri pra ver o que acontecia momento em que ouvi o vizinho 'Chupin' dizer para Nivaldo desce do carro e “troca” com o 'Carneiro', mas Nivaldo deu ré com o carro e ato contínuo 'Carneiro' apontou uma arma prata e efetuou dois disparos em direção do meu marido no carro. Acredito que acertando, pois o carro desceu. Corri para o carro e vi meu marido caindo, como se desfalecido e sangrando muito. Posso informar que 'Chupin' viu tudo e nada fez. Pedi socorro para 'Chupin', mas ele nada fez. Eu assumi a direção do carro, sentando no colo de Nivaldo, pois não consegui mudar ele de banco e corri para a UPA, mas combustível do carro no meio do caminho, aonde a Polícia chegou e providenciou o socorro. Posso informar ainda que ouvi 'Chupin' dizendo para 'Carneiro' fugir do local. 'Carneiro' saiu dirigindo uma Saveiro Cross de cor branca. Quanto a arma encontrada na minha bolsa posso informar que deva ter sido meu marido Nivaldo que a colocou no interior desta, pois eu não carrego arma comigo. Foi tudo muito rápido e não sei se Nivaldo tentou usar tal arma. Após o socorro até a UPA meu marido não resistiu e morreu. Informo que vi 'Chupin' pegar algo de 'Carneiro' e entrar para sua casa, mas não vi o que era. Finalmente, informo que Nivaldo e 'Carneiro' não se gostavam, mas ao que sei nunca teve qualquer desentendimento entre eles (...).”

Em juízo, a testemunha declarou que estava em sua casa e seu marido, Nivaldo, a chamou para ir ao centro. Ele saiu e lhe disse que esperaria no carro; que Nivaldo ingressou novamente em casa e lhe disse para esperar ali dentro; que Nivaldo deu ré no carro e escutou Chupim dizendo “desce e vai trocar com ele”; que EMERSON efetuava disparos nesse momento; que, quando Nivaldo ingressou novamente no automóvel, foi até ele e percebeu que estava ferido; que EMERSON e Nivaldo não eram amigos e não sabe se eram inimigos; que não sabia que Nivaldo estava armado, descobriu apenas quando a Polícia vasculhou sua bolsa e encontrou a arma dentro dela.

Em solo policial, a testemunha Jonas Roberto da Silva declarou que: “(...) Nesta data estou de serviço na companhia do policial Teixeira, sendo que por volta das 13h40min horas, fomos acionados a comparecermos na Rua Bom Sucesso, nº 371, Jardim Universitário IV, para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, porém, no trajeto, mais precisamente na Avenida Paraná, COHAB Beira Rio, nos deparamos com um veículo Gol parado e com a vítima em seu interior, bem como uma moça, esposa deste,

aos prantos e pedindo socorro, a qual informou que 'Carneiro' havia acabado de atirar em seu marido e que 'CHUPIN' tudo tinha presenciado. Imediatamente acionamos o resgate que levou a vítima para a UPA, onde foi constatado seu óbito. Havia sangue no interior do veículo e apuramos que os fatos se deram defronte a casa da vítima, ou seja, na Rua Bom Sucesso, 340, Jd. Universitário IV e que a própria vítima tentou sair com seu carro para receber socorro e a esposa estava na sua companhia, porém a vítima não conseguiu dirigir e sua esposa sentou no seu colo e assumiu a direção do veículo até àquele local onde o combustível do veículo acabou. Diante da autoria conhecida foram empreendidas buscas para localizar o autor e mensagem toda rede da Polícia Militar, porém até o momento este não foi localizado. Observamos ainda no interior do veículo da vítima haviam duas munições de pistola, as quais lá foram deixadas para arrecadação pelos peritos criminais. Ainda a esposa da vítima carregava uma bolsa e solicitamos que ela mostrasse o que tinha dentro, esta de pronto atendeu e lá havia uma pistola municada com três capsulas intactas e dois carregadores, um na arma com as munições e outro vazio, as quais foram apresentadas nesta delegacia. A esposa da vítima informou que não sabia nada daquela arma, inclusive está estava em estado de choque devido aos fatos. Apresentamos ela e a arma nesta delegacia, onde a mesma foi ouvida a respeito. Fomos informados que 'Carneiro' fugiu do local dirigindo um veículo Saveiro Cross de cor branca. Ainda no local originário quando a vítima tentou sair com seu veículo em busca de socorro acabou abalroando outros dois veículos lá estacionados. Não temos conhecimento do motivo do crime em questão (...)."

Em solo policial, a testemunha Rodrigo Teixeira da Silva declara que: "(...) No dia de hoje estou de serviço na companhia do policial Roberto e por volta das 13h40min horas, fomos acionados a comparecermos na Rua Bom Sucesso, nº 371, Jardim Universitário IV, para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, porém, no trajeto, mais precisamente na Avenida Paraná, COHAB Beira Rio, nos deparamos com um veículo Gol parado e com a vítima em seu interior, bem como uma moça, esposa deste, aos prantos e pedindo socorro, a qual informou que 'Carneiro' havia acabado de atirar em seu marido e que 'Chupin' tudo tinha presenciado. De imediato acionamos o resgate que levou a vítima para a UPA, onde foi constatado seu óbito. Havia sangue no interior do veículo e apuramos que os fatos se deram defronte a casa da vítima, ou seja, na Rua Bom Sucesso, 340, Jd. Universitário IV e que a própria vítima tentou sair com seu carro para receber socorro e a esposa estava na sua companhia, porém a vítima não conseguiu dirigir e sua esposa sentou no seu colo e assumiu a direção do veículo até àquele local onde o combustível do veículo acabou. Devido a autoria conhecida foram empreendidas buscas para localizar o autor e mensagem toda rede da Polícia Militar, contudo até o momento este não foi localizado. Observamos ainda no interior do veículo da vítima haviam duas munições de pistola, as quais lá foram deixadas para arrecadação pelos peritos criminais. A esposa da vítima carregava uma bolsa e solicitamos que ela mostrasse o que tinha dentro, esta de pronto atendeu e lá havia uma pistola municada com três capsulas intactas e dois carregadores, um na arma com as munições e outro vazio, as quais foram apresentadas nesta delegacia. A esposa da vítima informou que não sabia nada daquela arma, inclusive está estava em estado de choque devido aos fatos. Apresentamos ela e a arma nesta delegacia, onde a mesma foi ouvida a respeito. Fomos informados que 'Carneiro' fugiu do local dirigindo um veículo Saveiro Cross de cor branca. Ainda no local originário quando a vítima tentou sair com seu veículo em busca de socorro acabou abalroando outros dois veículos lá estacionados. Não temos conhecimento do motivo do crime em questão (...)."

Em juízo, as testemunhas Jonas Roberto da Silva e Rodrigo Teixeira da Silva declararam o que ouviram de Gabriela Cheron Vieira, a qual estava em estado de choque durante a entrevista. Ambos afirmaram que a esposa da vítima relatou que EMERSON havia efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu seu marido. Acerca dos fatos que efetivamente visualizaram, ambos afirmaram que havia cápsulas intactas dentro do automóvel da vítima e por isso suspeitaram que poderia haver uma arma ali dentro; que revistaram a bolsa da esposa da vítima e encontrou uma arma de fogo.

Em juízo, a testemunha Fernando Manzaneles Padilha, investigador responsável pelas

análise das imagens, relatou que é possível observar que, quando EMERSON, o filho deste e Alessandro entram no veículo para sair, Nivaldo emparelha seu automóvel; que, nesse momento, os três desceram do veículo e ingressaram na residência de Alessandro; que Nivaldo desceu do carro e conversou com Alessandro, e posteriormente ingressou em seu automóvel e deu a ré; que EMERSON saiu da casa de Alessandro com um objeto na mão que acredita se tratar da arma de fogo, porque apontava na direção de Nivaldo; que EMERSON e Alessandro saem na rua, seguindo o carro de Nivaldo por cerca de 20 metros e posteriormente retornam à casa deste último; que Nivaldo sai de seu carro portando uma arma de fogo; que EMERSON fica escondido no portão, sempre apontando para Nivaldo; que Nivaldo se esconde atrás de uma pilha de tijolos, depois atravessa a rua correndo para o mesmo lado na rua em que fica a casa de Alessandro; que pela qualidade dos vídeos não é possível visualizar toda a dinâmica dos fatos; que, após Nivaldo ser atingido, ele corre para seu automóvel e dá partida, colidindo com os automóveis do outro lado da rua; que, pelas imagens não é possível precisar quem deu início aos fatos.

A testemunha José Antônio Rubinho de Araújo, investigador de polícia, relatou que ambos os envolvidos ostentam passagens policiais e que soube que tinham desavenças em razão da atual companheira de Nivaldo ter se envolvido amorosamente com EMERSON anteriormente; que acredita, pelas imagens, que EMERSON apontou a arma para Nivaldo, enquanto ele dava a ré em seu veículo, e Nivaldo efetuou o disparo; que não sabe dizer se EMERSON atirou naquele momento, até porque não foram encontrados projéteis, mas dificilmente ele erraria um disparo a curta distância se tivesse atirado.

A testemunha Alessandro Martins da Silva relatou que já foi agredido e ameaçado por Nivaldo.

A testemunha Letícia Pupin Leal disse que Nivaldo arrumava confusão com muitas pessoas da cidade. Disse que conhecia sua esposa e que já presenciou conduta de cunho ameaçador de Nivaldo em relação a EMERSON.

O informante Olavo Cesar Andrade Pereira relatou que já foi agredido e ameaçado por Nivaldo, em razão dos ciúmes que a vítima tinha da mulher.

O informante Jeferson Tiago Bergamasco Pereira relatou também que já presenciou ameaças da vítima em razão de ciúmes que tinha de sua mulher.

O informante Fábio Henrique Zago relatou que era amigo de EMERSON e Nivaldo e sabe que este último já ameaçou o primeiro.

O informante Paulo Henrique Rodrigues de Melo dos Santos relatou que Nivaldo lhe enviou um áudio no dia 15/03/2021 com conteúdo ameaçador porque ele tinha ciúmes de sua esposa.

O acusado EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) No dia 04/10/2021 estava na casa da vó de sua esposa quando Alessandro ligou para o declarante e solicitou a este que fosse até sua casa para levá-lo até o lava-jato, a fim de pegar sua camionete que lá estava. Alessandro mora em frente à casa de Nivaldo. O declarante pegou seu filho Kauã, entrou com ele em seu veículo, VW Saveiro Cross de cor branca e foi até a casa de Alessandro. Ao chegar naquele local desceu em companhia de seu filho, tocou a campainha da casa de Alessandro e viu que Nivaldo estava discutindo com Gabriela no portão da casa deles. Quando Nivaldo viu o declarante ele começou xingá-lo de "vagabundo, vacilão, safado e talarico" e o ameaçou dizendo que iria matar o declarante e sua família, neste momento com o declarante estava com seu filho de três anos de idade, pediu para que Nivaldo parasse com aquilo "Por favor cara eu não quero problema com você, olha o que você tá falando eu to com o meu filho aqui ó". Não xingou Nivaldo de volta e nem o ameaçou. Diante disso Nivaldo entrou no carro dele, VW gol de cor branca, sozinho e deu ré, cerca de 40m, quando então "Ele desceu do carro, deu dois passos, voltou no carro e pegou a arma", "viu que ele se abaixou dentro do carro", o declarante viu quando Nivaldo apontou esta arma contra o declarante e seu filho e disparou, não se recorda quantas vezes, neste momento o declarante gritou para Nivaldo "Olha o meu filho, pelo amor de Deus! Olha o meu Filho!!! Pelo Amor de Deus! PARA! PARA!", e também se abaixou junto com seu filho na lateral de seu veículo e pediu para seu filho entrar dentro de seu carro. Sabe que Nivaldo diante disso atravessou a rua, indo para o lado da calçada onde estava o declarante, indo

ao seu encontro, como o declarante estava abaixado aproveitou e pegou sua arma, que estava embaixo do banco do passageiro. Quando Nivaldo estava a cerca quinze metros do declarante, Nivaldo disparou, outra vez, mas não sabe quantas vezes, quando então o declarante abaixado como estava disparou duas vezes na direção de Nivaldo. Após isso Nivaldo retornou ao carro dele e acelerou na direção do declarante, batendo este carro contra um carro Fiat Uno que estava em sua frente e este carro bateu no veículo que o declarante estava, danificando a traseira deste. Neste momento Alessandro abriu o portão da casa dele e perguntou o que estava acontecendo, perguntando sobre o filho do declarante. Diante disso Alessandro disse para o declarante ir embora. O declarante entrou em seu veículo e foi embora junto com seu filho. A arma utilizada pelo declarante foi jogada, no rio, na ponte rododferroviária, após a placa de divisa de estado. O declarante estava escondido em uma fazenda próximo a cidade de Cassilândia junto com seu filho. Aduz que quando disparou na direção de Nivaldo não teve a intenção de o matar, mas sim de defender seu filho e sua própria vida. Esclarece que somente andava com uma arma de fogo em seu automóvel por conta das ameaças de Nivaldo contra o declarante, "Eu cismava de ir na casa de Alessandro por conta disso", pois Nivaldo morava de frente. O problema que havia entre Nivaldo e o declarante era que Gabriela foi namorada do declarante há oito anos. O declarante não tem filhos com Gabriela. Aduz que em três ocasiões, quando Gabriela estava com Nivaldo e eles brigavam, Gabriela mandou mensagem para o declarante, contudo em todas as vezes o declarante bloqueava ela, sendo que desta última vez Gabriela mandou a seguinte mensagem para o declarante "A mãe tá on", não respondeu esta mensagem, tal fato aconteceu há oito meses. Sabe que por conta de Gabriela, Nivaldo "ameaçava um monte de gente". Em uma das ocasiões, há cerca de seis meses, o declarante caminhava próximo ao Colégio COC, quando Nivaldo o encontrou, Nivaldo veio com a mão na cintura na direção do declarante, este temendo por sua vida saiu correndo para o meio do mato, após os fatos se dirigiu até esta Delegacia para o registro da ocorrência policial, quando se deparou com Nivaldo parado de frente esta delegacia com Jetta Branco, nesta ocasião ele ameaçou o declarante dizendo "Se eu registrasse ocorrência ele iria dentro da minha casa e mataria minha família inteira", diante disso não registrou esta ocorrência. A arma utilizada pelo declarante foi um revólver calibre trinta e oito com cinco tiros, arma esta que era de seu finado avô. Não tinha documento de posse e nem porte desta arma. Com esta última o declarante correu de Nivaldo por cerca de três vezes. Alessandro não viu como se deu os fatos. Não se recorda de ter ouvido Alessandro dizer para Nivaldo descer do carro e "trocar" com 'Carneiro' (...)"

Em juízo, o réu declarou, em breve síntese, que foi até a casa de Alessandro com seu filho para lhe prestar um favor; que, nesse momento, encontrou a vítima (Nivaldo) que começou a ameaçá-lo de morte; que Nivaldo veio com seu automóvel e parou do lado e continuou as ameaças, dizendo que não era para passar naquela rua senão o mataria; que o depoente andava armado porque Nivaldo já o ameaçava há alguns meses; que a vítima retornou a pé e continuou as ameaças; que Nivaldo dizia que o acusado tinha mandado mensagens para a mulher dele; que, após diversas ameaças em frente ao portão da casa de Alessandro, Nivaldo realizou um disparo de arma de fogo; que o depoente se abrigou atrás do portão e gritou 'olha meu filho, pelo amor de Deus'; que a vítima entrou no carro e o acusado foi em direção dele e perguntou se estava louco; que a vítima desceu armada do carro e o depoente se abrigou atrás do portão; que a vítima realizou outro disparo de arma de fogo em sua direção e o depoente realizou outro disparo que atingiu o ombro da vítima; que Nivaldo foi para o carro e saiu, mas bateu em outro carro; que o depoente ficou apavorado e fugiu para o sítio de um tio; que jogou a arma utilizado no crime fora; que contatou um advogado e, após 15 dias, apresentou-se espontaneamente; que, no momento em que o depoente foi em direção ao veículo da vítima, não apontou a arma que estava em sua cintura.

Pois bem.

Da impronúncia do acusado

O MP e a Defesa pugnaram pela impronúncia do acusado em relação ao crime de homicídio.

No entendimento deste Juízo, tendo o processo penal, à luz da Constituição Federal,

natureza acusatória, o Juiz, via de regra, não deve efetuar a pronúncia do acusado cuja impronúncia o próprio Ministério Público, titular da ação penal, pleiteou - salvo em situações excepcionalíssimas decorrente de manifesta afronta à prova produzida nos autos.

Nesse sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:

(...). O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as poucas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

(STF - AP: 976 PE - PERNAMBUCO 0011603-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-087 13-04-2020)

Com efeito, o art. 385 do Código de Processo Penal deve ser lido e interpretado ponderadamente, de maneira a permitir a condenação (ou pronúncia, como no caso) em hipóteses excepcionais, em que o pedido do órgão acusador afronte manifestamente a prova amealhada.

No presente caso, o pedido do órgão ministerial não se revela flagrantemente contrário à prova dos autos.

Conforme discorreu o órgão de acusação:

"(...) a prova produzida indica que no dia dos fatos o acusado Emerson efetuou o disparo que levou à morte de Nivaldo. Ocorre que a própria vítima estava armada no dia dos fatos e, segundo laudo de fls. 374/381, também ela chegou a efetuar disparo de arma de fogo.

O confronto balístico, portanto, indica que a vítima Nivaldo efetuou ao menos um disparo com sua arma.

Ao término da instrução, o que se nota é que não restou clara a dinâmica dos fatos, pois apesar de haver câmeras de segurança na rua onde ocorreu o evento, não houve a captura de toda sequência de atos, bem como a resolução do vídeo, por vezes, é insatisfatória.

A testemunha policial Robinho, neste ponto, indica que, após analisar os vídeos, concluiu que o acusado Emerson se equipou primeiro com a arma de fogo, mas a vítima, ao que lhe parece, efetuou o primeiro disparo. O investigador Fernando Padilha, por sua vez, disse não ser possível precisar quem deu início aos disparos de arma de fogo.

O laudo pericial confeccionado pelo perito Antônio Luis Brassalotti, indica às fls. 116 que Nivaldo efetuou um disparo de arma de fogo antes de ser alvejado. Todavia, não aponta se houve outros disparos e quem os efetuou.

Tanto Gabriela Cheron - esposa da vítima - quanto o acusado relatam, respectivamente, que Emerson e Nivaldo efetuaram múltiplos disparos contra seus oponentes.

Embora Gabriela e Emerson indiquem que foram diversos os disparos realizados, a perícia balística e a perícia das imagens de segurança não corroboram quaisquer dos relatos, razão pela qual remanesce dúvida a respeito do que ocorreu na ocasião, já que houve a apreensão e perícia apenas de um cartucho e uma munição deflagrados. Esse cenário de incerteza, aliás, que é reforçado pelo laudo do aparelho celular da vítima, o qual indicou que Nivaldo tirara uma foto do emplacamento do carro de Emerson instantes antes da troca de tiros. Não se sabe por qual motivo e o que objetivava ele quando registrou aquela foto, e se assim o fez em razão de desavenças anteriores com o acusado. (...)

O conjunto probatório, como apontado pela Acusação em alegações finais, permite concluir pela ausência de indícios suficientes de autoria, a fim de justificar a submissão do acusado ao julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

De fato, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. No entanto, apesar de não ser exigido a certeza da autoria, é certo que nem toda dúvida é apta a fundamentar a pronúncia,

pois apesar de não exigir certeza, exige-se certa probabilidade, não se contentando a lei com a mera possibilidade.

Na lição do professor Sérgio Marcos Pitombo, o provável e o possível não se confundem. Enquanto o possível é um juízo neutro – havendo elementos tanto em um sentido quanto em outro, sem qualquer preponderância –, o provável é um juízo que desponta minimamente parcial, existindo mais elementos em um sentido do que em outro. Com efeito, o possível abrange, inclusive, aquilo que raramente acontece. Nesse contexto, em que pese não haja prova manifesta de que o acusado tenha agido em legítima defesa, a prova oral e documental colhida – em especial o depoimento das testemunhas que apontaram a agressividade da vítima e os laudos periciais de fls. 85/131, 216/222 e 374/382 – geraram considerável incerteza quanto aos indícios suficientes de autoria, na medida em que o acusado era efetivamente ameaçado e perseguido pela vítima.

Dessa forma, a melhor medida é a impronúncia do acusado, decisão esta que não fará coisa julgada material, pois, caso ulteriormente surjam novos elementos que corroborem os indícios suficientes da autoria, permitir-se-á a pronúncia. Assim, ante a ausência de elementos suficientes que garantam indícios da autoria do crime e permitam o prosseguimento do feito, a impronúncia do acusado é a medida que se impõe.

Do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03

O acusado confessou que, antes mesmo dos fatos denunciados, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, declarando que, após utilizá-la, livrou-se da arma lançando-a no rio. A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

As imagens das câmeras de vigilância não deixam dúvidas de que o acusado portava arma de fogo, utilizando-a no dia dos fatos (Laudo pericial de fls. 85/131).

O laudo pericial de fls. 374/382 concluiu que o projétil que atingiu a vítima trazia características compatíveis com munição de armas com calibre .38, as quais são de uso permitido.

Por fim, o crime de porte de arma de fogo antecedeu o potencial crime de homicídio, sendo perpetrado com dolo autônomo, não consistindo em mera fase preparatória deste último delito.

Assim, de rigor a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) Diante das várias reincidências do acusado (autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541; 0004216-11.2015.8.26.0541; 0000017-72.2017.8.26.0541; 0002567-11.2015.8.26.0541; 0002121-37.2017.8.26.0541; 0002464-33.2017.8.26.0541 e 0003133-23.2016.8.26.0541 – fls. 149/159), utilizo três delas (autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541 e 0004216-11.2015.8.26.0541) como antecedentes criminais.

Nesse sentido, precedente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15016905320218260228 SP, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/01/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022.

c) Não há elementos que permitam valorar a conduta social do acusado, pois não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais.

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) Não se aplica o comportamento da vítima por se tratar de crime difuso, sem sujeito passivo determinado;

f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.

Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt "as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes". Bittencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Com efeito, o descarte da arma de fogo que portava inseriu-se no plano de execução do agente a fim de dificultar a investigação criminal, de maneira que tal circunstância deve ser valorada em seu prejuízo.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em segunda fase, milita favoravelmente ao denunciado a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea "d", do CP). Noutro viés, está presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em razão de ostentar condenação transitada em julgado antes dos fatos aqui descritos (autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541; 0004216-11.2015.8.26.0541; 0000017-72.2017.8.26.0541; 0002567-11.2015.8.26.0541; 0002121-37.2017.8.26.0541; 0002464-33.2017.8.26.0541 e 0003133-23.2016.8.26.0541 - fls. 149/159).

No caso, as condenações nos autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541 e 0004216-11.2015.8.26.0541 já foram utilizadas como antecedentes criminais.

Em que pese tenha sido pacificado no Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, no presente caso, tal solução não se mostra a mais indicada em virtude de se tratar de réu multirreincidente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". III - In casu, tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multireincidência do paciente. (...). Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

No caso em comento, extrai-se que o réu possui condenações transitadas em julgado por crimes praticados antes dos fatos sob julgamento, razão pela qual a agravante

da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, com fundamento no artigo 67 do Código Penal.

Portanto, agravo a pena-base em 1/4, resultando na pena provisória de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, bem como 15 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, fixa-se a reprimenda em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, bem como 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização

da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021) Dessa forma, o cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

(i) IMPRONUNCIAR o réu EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal;

(ii) CONDENAR o réu EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Em que pese parcela das razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito não mais subsistam, é certo que a cautela ainda é recomendada uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Uma vez realizada a perícia, decreto o perdimento da arma e das munições em favor da União (art. 91, alínea "a", do Código Penal). Encaminhem-nas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003

Quanto aos bens pessoais da vítima apreendidos a fls. 19 (celular, carteira, documentos pessoais, cheque, etc), autorizo a restituição - caso já não tenham sido devolvidos.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA